

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、火災保険金をだまし取る目的で、同居する家族が不在の間に、自宅に放火して焼失させ、その後、火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲には、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。
2. 甲は、強盗目的で、乙方に侵入した上、乙及び丙をそれぞれ殴打して緊縛し、その際、両名に怪我を負わせ、乙が管理していた現金100万円を強取した。この場合、甲には、住居侵入罪及び1個の強盗致傷罪が成立し、これらは牽連犯となる。
3. 甲は、乙を教唆して丙占有の自動車を盗むことを決意させ、乙にこれを実行させた後、乙から頼まれて、同自動車を預かり保管した。この場合、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、これらは牽連犯となる。
4. 甲は、乙を殺害して金品を強取しようと考え、甲の自宅内で乙を殺害して現金を強取した後、引き続き、その死体を自宅の床下に埋めて遺棄した。この場合、甲には、強盗殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは併合罪となる。
5. 甲は、乙名義で預金口座を開設する目的で、同人に成り済まし、同人名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、乙名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

|         |               |     |
|---------|---------------|-----|
| No198   | 罪 数           | 正答率 |
| 共通R2-15 | 正 解 2、3 (順不同) | 67% |

## 1 正しい

大判昭5.12.12により、本記述は正しい。

本記述と同様の事案において、判例は、放火罪と詐欺罪は併合罪になるとしている。したがって、甲には、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。

## 2 誤っている

本記述は、甲には、住居侵入罪及び1個の強盗致傷罪が成立し、これらは牽連犯となるとしている点で、誤っている。

最決昭29.5.27(百選I106事件)。住居侵入罪と強盗罪は牽連犯の関係にある(大判明45.5.23)が、2個の強盗罪は併合罪の関係にあるため、かかる場合の罪数処理が問題となる。住居に侵入して3人を殺害した事案において、判例は、「3個の殺人の所為は所論1個の住居侵入の所為とそれぞれ牽連犯の関係にあり刑法54条1項後段、10条を適用し一罪としてその最も重き罪の刑に従い処断すべきである」としている。このように、本来併合罪の関係にある複数の罪が、各々と科刑上一罪の関係にある共通の他の罪を媒介として全体として一罪となるとする考え方を、「かすがい現象」という。したがって、甲には、乙及び丙に対する2個の強盗致傷罪が成立し、それぞれ1個の住居侵入罪と牽連犯(54条1項後段)となり、全体として一罪となる。

## 3 誤っている

本記述は、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、これらは牽連犯となるとしている点で、誤っている。

最判昭25.11.10。判例は、本記述と類似の事案において、窃盗教唆罪と盗品等有償譲受け罪は牽連犯とはならず併合罪(45条前段)になるとしている。その理由として、判例は、窃盗教唆と盗品等有償譲受けとの間には通常手段又は結果の関係はないということを挙げている。本記述は、盗品等保管罪の事案であるが、判例の立場に従えば、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、これらは併合罪となる。

## 4 正しい

大判明44.7.6により、本記述は正しい。

本記述と類似の事案において、判例は、殺人罪と死体遺棄罪とは併合罪になるとしている。その理由として、判例は、死体遺棄行為は常に必ず殺人行為を伴うものではなく、人を殺した後に死体を遺棄する行為は別罪を構成することを挙げている。本記述は、強盗殺人罪の事案であるが、判例の立場に従えば、甲には、強盗殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは併合罪となる。

## 5 正しい

大判明42.1.22により、本記述は正しい。

本記述と同様の事案において、判例は、詐欺罪、有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立する場合は牽連犯となるとしている。したがって、甲には、有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

以上により、誤っている記述は2と3であり、したがって、正解は肢2と肢3(順不同)となる。